



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת- שלוחת עכו

מס' תיק: 8/148/2017 + 8/607/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקח על רישום המקרקעין יובל
וסרקרוג

- | | |
|---|---|
| <p>1. התובעים בתיק
8/148/17</p> <p>2. נחמני עידן
לידר את רפאלי בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד אביתר שרגאי
שד' פל-ים 6, ת.ד. 588, חיפה</p> <p>3. רועי שוורצמן
באמצעות ב"כ עו"ד א. לוגסי
שד' משה גושן 2, קריית מוצקין</p> <p>נגד</p> <p>מול'ז לאה
באמצעות ב"כ עו"ד נדב מאיוסט
קרן היסוד 45, קריית ביאליק</p> | <p>התובע בתיק
8/607/16</p> <p>הנתבעת:</p> |
|---|---|

פסק דין

התובעים מבקשים לחייב את הנתבעת לסלק את ידה מהרכוש המשותף, ובפרט מחלק מהחצר האחורית אותה רצפה וגדרה, וכן ממחסן שהורחב על ידה לאחר שהוסב השימוש בו למגורים.

1. עסקינן בבית משותף שנמצא ברח' אורנים 20 בקריית ביאליק, וידוע כגוש 11555 חלקה 147. הבית נרשם כבית משותף בפנקסי המקרקעין ומכיל 4 דירות.
2. התובעים הם בעלים של שתי דירות בבית. הנתבעת בעלים של דירת הקרקע עוד משנות ה-60 של המאה הקודמת, כאשר כבר בשנת 1965 הוסיפה מחסן בשטח של כ-9 מ"ר, על פי היתר שהתקבל כדין (היתר שכלל גם הרחבה של הדירה – **"הוספת חדר כניסה וסגירת מרפסת"** – ר' ההיתר – 1/3).
3. מאוחר יותר בשנת 1993 קיבלה היתר נוסף להוספת ממ"ד.
4. התובעים רכשו את דירותיהם בשנים האחרונות, ואינם מבקשים לסלק או להרוס את תוספות הבניה שקיבלו היתר. התובעים מבקשים רק להרוס את אותו חלק מהמחסן שהוגדל, "הרחבה" שלטענתם נעשתה שלא כדין, וללא היתר, וכן לסלק את ידה מהחצר האחורית אותה ריצפה וגידרה.
5. התובעת מס' 2 הגדירה היטב בסיכומיה את הסוגיה העיקרית שבמחלוקת:

"הנתבעת הרחיבה מחסן, בעל היתר, המצוי בחצר הבניין (להלן: **"המחסן"**). שאלת חוקיות הרחבה זו נתונה במחלוקת בין הצדדים. כן בנתה בחלק מחצר הבניין פרגולה, ריצפה את אותו חלק מחצר הבניין, וחסמה את המעבר אל חלקה האחורי של החצר (להלן כל אלה: **"העבודות"**)" סעיף 4 לסיכומי התובעת (ההדגשות במקור).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת- שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/148/2017 + 8/607/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טענות הצדדים

6. כאמור, לטענת התובעים, הנתבעת הרחיבה שלא כדין את המחסן של דירתה באופן שהוא כיום בנוי בשטח כולל של כ-23 מ"ר והפכה אותו ליחידת דיור נפרדת.
בנוסף טענו התובעים כי הנתבעת השתלטה שלא כדין על חלק מהחצר המשותפת, לאחר שריצפה אותה, בנתה פרגולה גדולה תחמה וגידרה אותה. עוד נטען, כי הנתבעת בנתה כניסה נוספת לחלקה ומונעת מבעלי הדירות להכנס לחלק האחורי של החלקה.
לטענת התובעים, יש לסלק בנייה זו ואת ההשתלטות על החצר, שנעשתה ברכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות וללא היתר בנייה.
7. התובעים הוסיפו וציינו כי הריסת המחסן לא תותיר את מי שמתגורר בו חסר קורת גג, שכן הדירה בה מתגוררת הנתבעת מכילה 5 חדרים, כך שקיים חדר פנוי גם עבור נכדה של הנתבעת.
8. **הנתבעת**, אישה מבוגרת, ניצולת שואה כבת 90, טענה כי לאחר מות ביתה וחתנה, היא זו שנאלצה לגדל את נכדיה, חלקם סובלים מבעיות בריאותיות ונפשיות, ובשל כך הורחב המחסן והוסב לשימוש למגורים עבורם, וחלקם מתגוררים בו.
9. לטענת הנתבעת, מדובר בתוספת בנייה שבוצעה על ידי בעלה המנוח לפני למעלה מ-20 שנה (בשנות ה-90 של המאה הקודמת) ותוספת שנבנתה בהסכמת כל בעלי הדירות דאז ובידיעתם, ומאז לא נעשה שום שינוי בשטח. לחילופין טענה, כי נוצר רישיון בלתי הדירה אותו התובעים אינם רשאים לבטל כיום.
10. הנתבעת טענה, כי התביעה הנוכחית הוגשה על ידי התובעים שרכשו את שתי הדירות בשנים האחרונות, כאשר עוד קודם לכן, הם היו מודעים היטב למצב השימושים הקיים בשטח. לטענתה התביעה הוגשה רק במטרה לקדם פרויקט של תמ"א 38. לטענתה הפיכת הבית לאתר בנייה, עשויה להוביל להתדרדרות חמורה במצבה מפאת גילה ומצבה.
11. באשר לעדות שמסרה בדיון ההוכחות, טענה הנתבעת, כי ככל שנפלו אי דיוקים בעדותה, הדבר נבע בשל מצבה הרפואי וגילה המופלג. הנתבעת מדגישה, כי הייתה פעילה חברתית מוכרת ומוערכת בעיריית קריית ביאליק, ואף קיבלה אות של יקירת העיר.

בעלי הדין והתביעות שהוגשו

12. יובהר כי בתחילה הוגשה התביעה בשנת 2016 על ידי שניים מהתובעים (שוורצמן רועי ועידן נחמני) בתיק 8/607/16 **שוורצמן רועי ואח' נ' מילאז'.**
13. באוקטובר 2016 הודיע מר עידן נחמני, כי הוא מבקש למחוק את שמו כתובע בתיק 8/607/16, ובהתאם הוריתי ביום 2.11.16 על מחיקתו מהתביעה. בדיון ההוכחות טען כי ביקש למחוק בתחילה את התביעה כי סבר שיגיע להסכמות עם הנתבעת, ולאחר שאלה לא הושגו חזר והגיש תביעה חדשה בשנת 2017.
14. ביום 27.2.2017 חזר והגיש מר נחמני את התביעה הנוכחית נגד הנתבעת (במסגרת תיק 8/148/17).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת- שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/148/2017 + 8/607\2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

15. לאחר מכן במהלך שנת 2017 מכר התובע מס' 1, עידן נחמני את דירתו לתובעת מס' 2, חברת "לידר את רפאלי" ולכן ביקש להחליף את זהות התובעת בהליך. בהחלטת מיום 23.5.17 הוריתי על צירוף חברת לידר רפאלי כתובעת נוספת בתיק.

16. במהלך ניהול ההליך, נעשו נסיונות רבים להביא את הצדדים לידי הסכמות, ולאחר שניסיונות אלה לא צלחו, הוגשו תצהירי הצדדים, התקיים דיון הוכחות ביום 7.7.2020 ולאחריו הגישו הצדדים את סיכומיהם.

זכויות הצדדים

17. התובע מס' 1, עידן נחמני, רכש את הדירה (תת חלקה 4) בשנת 2013 או בסמוך לכך, וכאמור בשנת 2017 מכר את הדירה לתובעת מס' 2, חברת לידר רפאלי.

18. התובע מס' 3, מר רועי שוורצמן הוא הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 1. התובע רכש את דירתו בשנת 2013, או בסמוך לכך.

19. **הנתבעת** היא בעלים של דירת קרקע הידועה **כתת חלקה 2**, ורשומה כבעלת הדירה עוד משנת 1960.

המצב התכנוני

20. כאמור, הנתבעת קיבלה בשנת 1965 היתר להוספת מחסן לדירתה, וכפי שנרשם בהיתר עצמו, זה התייחס לעבודות בניה הכוללות: **"הוספת חדר כניסה סגירת מרפסת והקמת מחסן"** (נ/1). בשנת 1993 קיבלה היתר להרחבת דירתה ולבניית ממ"ד.

התובעים אינם מלינים על עבודת אלה.

21. בשלב כלשהו במהלך שנות ה-90 של המאה הקודמת הרחיבה הנתבעת את המחסן של דירתה והפכה את השימוש בו למגורים. הנתבעת לא הציגה היתר או מסמך כלשהו היכול לתמוך בטענותיה, כי גם ההרחבה של המחסן בוצעה בהיתר.

22. יתרה מכך, התובעים הציגו מכתב של הוועדה המקומית מיום 02.05.16 שם אישרה הוועדה, כי נבנתה יחידת דיור ללא היתר (אותו מחסן שהורחב).

באותו מכתב צוין כי ביום 23.07.15 נערכה ביקורת בשטח מטעם הוועדה, ונמצא בחזית המזרחית האחורית של הבית, כי קיימת יחידת דיור בשטח 23 מ"ר ללא היתר בנייה, ממכתב זה אף עולה כי הנתבעת גם זומנה לוועדה המקומית כדי לתת הסבר לאותן עבירות בנייה (מכתב הוועדה, סומן ת/2):

"קיימת יחידת דיור בשטח של כ-23 מ"ר וכל זאת ללא היתר בניה כחוק, (ראוי לציין כי התוספת נבנתה לפני מספר רב של שנים וזאת בהסתמך על תצ"א הנמצאים במשרדינו)..."

23. הנתבעת לא הפריכה ממצאים אלה של הוועדה המקומית - במסגרת עדותה לפני, הנתבעת לא ידעה אם התקבל היתר בנייה אם לאו, ולא הציגה היתר נוסף מלבד ההיתר משנת 1965 (ר' עמ' 2 שורות 45-47 לפרוטוקול מיום 07.07.20).

חרף אותה חריגה, הוועדה המקומית הוציאה כאמור מאוחר יותר בשנת 1993, היתר להרחבת דירת הנתבעת ולבניית ממ"ד, מבלי שדרשה כתנאי להיתר את הריסת התוספת למחסן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת- שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/148/2017 + 8/607/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

24. כפי שיפורט להלן, הנתבעת לא הוכיחה כי יש ברשותה את ההסכמות הקנייניות הדרושות לצורך תפיסת חזקה ייחודית בחלקים מהחצר המשותפת, לרבות לצורך בניית אותה יחידת דיור נפרדת בחלקה. חרף זאת הנתבעת הוכיחה כי היא בעלת רשות בלתי הדירה באותם מקרקעין בגינם יש לדחות נגדה את התביעה לסילוק יד.

25. יוטעם, ישנה נפקות ממשית להבחנה זו, שכן בהעדר הגנה קניינית משלא הושגו ההסכמות הקנייניות הדרושות, אפשר שבעתיד עם שינוי נסיבות שיצדיק זאת, יהיו רשאים התובעים, או בעלי הדירות האחרים, לדרוש את סילוק המחסן ואת סילוק היד מהחצר המשותפת. הנתבעת לבדה, כבת רשות, רשאית להחזיק בחלק מהחצר ובמחסן עד לאריכות ימיה.

להלן יפורטו בהרחבה הנימוקים למסקנות אלה:

העדר זכות קניינית

כפי שיפורטו להלן, הנתבעת לא הוכיחה כי יש ברשותה את הסכמות קנייניות לסיפוח החצר, או להגדלת המחסן ולהפיכתו ליחידת מגורים, וזאת לאור אלה:

26. אין מחלוקת כי חלקי החצר המקיפים את הבית הם רכוש משותף. לבית לא נרשם תקנון מוסכם ולא נרשמו הצמדות כלשהן. בנוסף דירת הנתבעת הוגדרה כדירה ללא מחסן. למעשה אף אחת מהדירות בבית לא נרשמה עם מחסן וגם המחסן שנבנה בעבר כחלק מההיתר משנת 1965 אינו משתקף במסמכי הבית המשותף (לא בוצע תיקון לצו הבית המשותף).

27. הנתבעת בפועל תפסה חזקה ייחודית בחלק מהחצר האחורית, ריצפה אותה, ואף אישרה את מיקום הגדר התוחמת חלק מהחצר (ר' 2/נ, עמ' 8 לפרוט' דיון מיום 7.7.20).

תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף שהיא דומה במהותה להצמדה קניינית של הרכוש המשותף לאחת הדירות, מחייבת הסכמה מפורשת של כל בעלי הדירות בבית, שכן היא שוללת לצמיתות את זכותם של יתר בעלי הדירות לעשות שימוש באותו חלק מהרכוש המשותף, ולכן לא די בהסכמת הרוב (סעיף 62א) לחוק המקרקעין; ת"א (מחוזי י-ם) 18410/90 **בן דוד נ' קסיס** (פורסם בנבו), וכן ת"א (י-ם) 5826-08-11 **יוסוב מקסומוב נ' מאגמאטופ בע"מ** (פורסם בנבו).

28. **שימוש בלעדי בחצר** - על כן לצורך תחילת החצר, לרבות לצורך ריצוף חלקים מהחצר נדרשת הסכמה קניינית מפורשת שכן יש באלה, כדי להפוך את דירת הנתבעת לדירה עם חצר צמודה, בפרט שבדירת הנתבעת גם נפתח פתח יציאה לאותה חצר.

29. **המחסן** - כך גם ביחס לבניה ברכוש המשותף, ואף לצורך בניה על חלק הצמוד לאחת הדירות יש להוכיח הסכמות של כל בעלי הדירות.

30. המחוקק ביקש להקל על בעל דירה המבקש להרחיב את דירתו, כך שנקבע כי ביחס ל"הרחבת דירה" די ברוב של 75% מבעלי הדירות אשר 2/3 חלקים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם (תיקון מס' 18 לחוק)

בית המשפט העליון בפרשת עטייה קבע, כי כדי שבנייה ברכוש המשותף תחשב כ"הרחבת דירה" נדרשת "סמיכות פיסית" בין אותה תוספת בנייה (אותה "הרחבה") לבין הדירה עצמה (רע"א 1462/10 **דוד עטייה נ' ליאור שגיא** (פורסם בנבו - להלן: "פרשת עטייה").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת- שלוחת עכו

מס' תיק: 8/148/2017 + 8/607/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טיבן של ההסכמות הדרושות לצורך בניה ברכוש המשותף או לסיפוח חלקים מהחצר לדירת הנתבעת

31. בהתאם לפסיקה, בעל דירה המבקש להוכיח כי שאר בעלי הדירות הסכימו לסיפוח חלקים מהשטח המשותף לדירתו או לבניה ברכוש המשותף, נדרש להוכיח **הסכמה ברורה ומפורשת** של אותם בעלי דירות, שכן למעשה בניה כזו יש בה משום ויתור על זכות קניינית, ואפשר שתמנע בעתיד בניה של בעל הדירה האחר (גם לצורך סעיף 71ב לחוק המקרקעין, העוסק ב"הרחבת דירה").

32. באשר לטיבה של אותה הסכמה נפסק, כי לא ניתן ללמוד על הסכמה כזו באופן משתמע. נדרשת ידיעה והסכמה מלאה של הצד המוותר על זכותו (ר' למשל ע"א 7388/97 **עזבון משה זמיר ז"ל נ' יעל דולב (שמיר)** (פורסם בנבו); ע"א 19/81 **ביבי נ' הורברט**, פ"ד, לז(2), 497; ע"א 5043/96 **גלמן נ' הררי**, פ"ד, נד(3), 393; ע"א (מחוזי י-ם) 9502/06 **רונית לומברוזו נ' קובנר מיכאל ואח' (פורסם באתר נבו 7.8.07)**, ע"א 271-85 **הילמן נ' רוזן** (פורסם בנבו) וע"א 13721-05-16 **גבאי ואח' נ' הקש** (פורסם בנבו) וכן א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, בעמ' 113).

33. מכאן שגם, לא די בכך שחלק מבעלי הדירות אינם מתנגדים באופן פעיל לאותה בניה, או שדעתם לא נשמעת, יש להוכיח הסכמה פוזיטיבית מפורשת לאותה בניה, גם אם הסכמה זו תינתן בעל פה:

"...אין די בהעדר התנגדות ואין די בהסכמה משתמעת, אלא יש צורך בהסכמה מפורשת, בין בכתב ובין בע"פ, ועל המערערים מוטל נטל הראיה להוכיח כי השיגו את ההסכמות הפוזיטיביות הנדרשות מהרוב הקבוע בחוק (ראו: רע"א 259/99 חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פד"י נה(3) 385, 402, ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פד"י לו(3) 78)." (עש"א (ת"א) 61803-03-15 **דסטגר אלון ואח' נ' אפרים גלברג ואח'** (פורסם בנבו) ההדגשות אינן במקור).

ר' בנוסף ע"א 815/81 **כליפא נ' שאול**, פד"י לו(3) 78.

מן הכלל אל הפרט

34. לאור הלכות אלה, הנתבעת לא הוכיחה, כי בעלי הדירות בזמנו נתנו את הסכמתם לבנייה זו, או לסיפוח החצר לדירתה. הנתבעת לא הציגה אסמכתא כלשהי התומכת בטענותיה. הנתבעת לא הציגה למשל, טופס הסכמת שכנים, או גרמושקה עם חתימות של בעלי הדירות. הנתבעת גם לא דאגה, ולמעשה כלל לא ביקשה, לזמן את בעלי הדירות, או מי מטעמם, לעדות.

35. בנוסף, משפחת שטרן אותה זכרה הנתבעת שהתגוררו בבניין, הגישו התנגדות לבקשה אחרת להיתר משנת 1993 הנוגעת לממ"ד (ר' עמ' 4 שורה 18 לפרוטוקול מיום 07.07.20 וכן מסמך ת/1, מכתב של הוועדה המקומית משנת 1993 שם התייחסה הוועדה להתנגדות של משי שטרן).

העובדה שלאחר מכן משפחת שטרן לא הגישה ערר על החלטת הוועדה המקומית, או לא יזמה הליך להפסקת הבניה ולסילוק המחסן, אין בה כדי להעיד על הסכמה קניינית לבניה ולסיפוח חלקים מהחצר המשותפת לדירת הנתבעת (בעניין זה ר' גם פסק דינו של בית המשפט העליון בעע"מ 795/19 **קנרוב טליאט נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה - מחוז תל אביב** (פורסם בנבו) שם נפסק כי נדרשת הסכמה פוזיטיבית של בעלי דירות, ולא די בהעדר התנגדות גם לצורך ההליך התכנוני).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת- שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/148/2017 + 8/607/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעת אף אישרה כי לא זכרה אם משפחת שטרן הסכימה לבנייה (ראה עמ' 4 שורה 15 לפרוטוקול מיום 07.07.20).

36. הנתבעת גם לא זכרה במפורש, מי מבעלי הדירות הסכים לאותה בנייה או לסיפוח של החצר. כך גם יש לקחת בחשבון כי הנתבעת ובעלה המנוח לא נקטו בהליך שנועד לאשר בדיעבד את בניית המחסן עוד בשנות ה-90 או בסמוך לאחר מכן, וגם לא במסגרת הבקשה להיתר שהוגשה בסמוך בשנת 1993 ונועדה לאפשר את הוספת הממ"ד לדירתה.

37. זאת ועוד, הנתבעת הציגה הסכם לפיו רכשה לכאורה בשנת 2011 זכויות בניה מאחת מבעלי הדירות האחרים בבית (הגב' קטן – הוגש וסומן ת/4). גם באותו מסמך לא נרשמה הסכמה מפורשת פוזיטיבית וברורה לכך שהנתבעת תעשה שימוש ייחודי ובלעדי בשטח החצר, או הסכמה לכך שהנתבעת תרחיב מחסן ותהפוך אותו ליחידת דיור.

38. זאת ועוד, אפילו אם שטח החצר הוקנה לנתבעת (ולכך אתייחס בהמשך שכן עולה לכל היותר כי התגבשה הסכמה לחלוקת השימושים ברכוש המשותף), היה עליה להוכיח הסכמה מפורשת לבניית המחסן. בכל פעם העלתה הנתבעת טענות שונות לגבי אופי ההסכמה לכאורה שניתנה.

39. טענת הנתבעת כי בעלי הדירות נתנו בזמנו את הסכמתם לבניה זו לא הוכחה והועלתה ללא תימוכין. לא הוכח, כי רוב בעלי הדירות אישרו הרחבה זו, ולמעשה לא הוכחה הסכמה קניינית של אף אחד מבעלי הדירות האחרים בבית. כאמור בעניין זה יש להוכיח הסכמה פוזיטיבית ולא די בהעדר התנגדות (בעניין זה ר' גם ע"א 13721-05-16 **גבאי ואח' נ' הקש** (פורסם בנבו)).

לאור כל אלה, הנתבעת לא הוכיחה כי קמה לה זכות קניינית לשימוש בלעדי בחלק מהחצר המשותפת או לצורך הרחבת המחסן ולהפיכתו ליחידת מגורים.

רשות הדירה

40. בנסיבות המיוחדות שלפני, הגם שלנתבעת אין זכות קניינית בשטחים נשוא המחלוקת לרבות לצורך מימוש זכויות בניה והרחבת המחסן, הרי שהוכח כי קמה לנתבעת רשות בלתי הדירה אותה אין לבטל, אך זכות זו עומדת לנתבעת בלבד. להלן הנימוקים:

41. להבדיל מוויתור על זכויות קנייניות, כאשר מדובר בזכות שימוש במקרקעין, ניתן ללמוד על הסכמה שכזו גם בדרך של שתירה, הסכמה מכללא, או לאור התנהגות הצדדים במהלך השנים.

בהתאם לפסיקה, חלוף זמן רב, מאז תפס המחזיק את הקרקע, כאשר משך אותו זמן נמנע בעל הקרקע מתגובה כלשהי על אף שידע על התפיסה, יכול להעיד על הסכמה ויצירת רישיון מכללא לשימוש במקרקעין (ע"א 32/77 **טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים**, פ"ד לא(3) 210 ור' גם ע"א (י-ם) **לומברוזו נ' קובנר** [פורסם בנבו] (7.8.07)).

42. בשונה מביטולה של זכות קניינית שהוענקה, הרי שביחס לרישיון לשימוש במקרקעין, הכלל הוא, שמדובר ברישיון הדיר, שניתן לבטלו, ובאופן עקרוני נותן הרשות רשאי בכל עת לחזור בו מההסכמה שהוענקה, עם גילוי דעתו של המקנה, שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון (ר' למשל ת"א (י-ם) 40796-10-10 **חברת דואר ישראל בע"מ נ' שמאי 6 ירושלים בע"מ** (פורסם בנבו) נ. זלצמן, **רישיון במקרקעין**, הפרקליט מב, 24, 57; וראה גם מ. דויטש, **קניין**, כרך ב' (התשנ"ט-1999) 414).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת- שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/148/2017 + 8/607\2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

רק לעיתים רחוקות ובמקרים חריגים, יהיה מקום להכיר ברישיון לשימוש במקרקעין שניתן בלא תמורה כבלתי הדיר מכוח השתק (ע"א 496/82 יצחק רוזן נ' יגאל סלונים, פ"ד לט (2) 337 (1985)). במקרים מיוחדים שבהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, ושהם, בהסתמך על הרישיון נוצרה צפייה אצל בעל הרישיון, כי הרשות ניתנה לצמיתות, ושיקולי הצדק יתמכו בכך, אפשר שתוכר רשות שימוש שאינה ניתנת לביטול.

כך למשל במקרים שבהם בהסתמך על הרישיון, השקיע בעל הרישיון כספים והשקעות במקרקעין, ושינה את מצבו לרעה, תוענק לבעל הרישיון הגנה מפני ביטול הרישיון. בנוסף יתכנו מקרים בהם יבוטל הרישיון בכפוף לתשלום פיצוי על ההשקעות שבוצעו.

בעניין זה ר' ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד ואח', פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס, פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה ואח', פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ ואח', פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן ואח', פ"ד לא(2) 127; בע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (פורסם באתר נבו)).

בע"א 483/16 חביבה יהודאי נ' חלמיש - חברה ממשלתית - עירונית לדיור שיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב בע"מ (פורסם בנבו), הוכר רישיון בלתי הדיר, זאת בהתבסס על מערכת חוזית שבין הצדדים ויחסי הכוחות בין בעלי הדין. תוצאת פסק הדין הכירה ברישיון בלתי הדיר במסגרת תביעה לסילוק יד, כל עוד בעל הרישיון הוא זה שעושה שימוש באותה זכות. כמו כן נפסק שם, כי לבתי המשפט מגוון רחב של תרופות וסעדים במסגרת דיני הרישיון במקרקעין.

43. עוד נפסק כי במקרים בהם מדובר ברשות הדירה, הרי שלצורך ביטול הרישיון, די בהגשת תביעה לסילוק יד (ר' ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת בית מדרש החסידים (פורסם בנבו)).

עוד על רשות במקרקעין בזיקה לבית משותף ר' עש"א (ת"א) 4361-05-17 רחל גלעדי נ' יגאל לייבה (פורסם בנבו) יחד עם ההפניות שם.

מן הכלל אל הפרט

לאחר שבחנתי את מכלול חומר הראיות ואת טענות הצדדים, מצאתי לדחות את התביעה, וזאת מהטעמים הבאים:

44. החלוקה הקיימת של החצר קיימת מזה עשרות שנים. התובעים לא הפריכו כי הנתבעת עושה שימוש ייחודי בחצר האחורית משך עשרות שנים, ולמעשה מאז שעברה להתגורר בבית:

ש': החלוקה של החצר הייתה ככה כשקניתי?

ת': מצב החצר היה ככה כשקניתי, לא יודע כמה זמן לפני זה היה ככה.

ש': גב' מולז טוענת שזה ככה 30 שנה ויותר בהסכמת שכנים, ניסית

לברר?

ת': היא אמרה שכולם מתו, אלה שנתנו את ההסכמה ולכן לא בדקתי

עם השכנים אם הסכימו בעבר לחלוקת החצר ולשימוש שלה. " (עמ' 21

ש' 29 – 36 לפרוט' מיום 7.7.20, דברים שמסר מר אורן רפאלי המנהל

של התובעת מס' 2).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת- שלוחת עכו

מס' תיק: 8/148/2017 + 8/607\2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

45. על בסיס חלוקה זו של החצר הרחיבו הנתבעת ובעלה המנוח, את דירתם במספר הזדמנויות לאורך שנים, כאשר בעלי הדירות אינם מלינים על הרחבות אלה, שבוצעו שנים לפני שהתובעים רכשו את דירותיהם:

א. בשנת 1965 הוציאו היתר בניה להוספת חדר כניסה, סגירת מרפסת ובניית אותו חלק מהמחסן שלגביו, התובעים אינם מבקשים את סילוק היד, לטענתם המחסן שנבנה בשטח של כ-9 מ"ר נבנה כדין, ההיתר צורף כנ"ל.

ב. בשנת 1993 הרחיבה הנתבעת את דירתה והוסיפה ממ"ד גם כן באותה חצר, כאשר גם להרחבה זו התובעים אינם מתנגדים.

עוד יש לציין בהקשר זה, כי הוועדה המקומית הוציאה לנתבעת היתר נוסף בשנת 1993 עבור תוספת מגורים בחזית אחורית בקומת קרקע כולל מרחב מוגן דירתי (ר' המוזכר במכתב הוועדה מיום 02.05.16 – ת/2). במסגרת זו לא דרשה הוועדה כתנאי להוצאת ההיתר להרוס את אותו מחסן שהורחב ולהפסיק את השימוש שנעשה בו למגורים.

ג. גם ההתנגדות של משפחת שטרן לאותה בניה הוגשה ככל הנראה ביחס להוספת הממ"ד. התובעים לא צירפו את מכתב ההתנגדות של משפחת שטרן שנשלחה לוועדה המקומית, ולא הציגו התנגדות כלשהי של בעלי הדירות למחסן שהורחב ולהסבת השימוש בו למגורים.

46. הרחבת המחסן והסבת השימוש בו למגורים נעשתה אף היא לפני עשרות שנים - גם המחסן שהורחב והוגדל ללא היתר לכ-24 מ"ר, והוסב השימוש בו למגורים, נעשה לפני עשרות שנים, בשנות ה-90 של המאה הקודמת. כאשר כל אותן שנים ארוכות התגוררו נכדיה או אחד מנכדיה של הנתבעת באותו מחסן. כך גם אישרו התובעים והוועדה המקומית.

התובע מר נחמני אישר בעדותו, כי שימוש זה נעשה לאורך שנים ארוכות:

י"ש': למיטב ידיעתך, ממתני החלק האחורי הזה של הגינה מרוצף, נמצא בשימוש פרטי של הגב' מולז?
ת': כל הזמן.

ש': 30 שנה קודם? כמה זמן?

ת': השכנים העידו שתמיד הוא היה גר שם הנכד, או הנכדים, או האמא שהייתה בחיים.

ש': זה נבנה אחרי שהיא נפטרה. אתה קנית ב-13-2012, מתי למיטב ידיעתך הנתבעת התחילה להשתמש שימוש "פרטי" בחלק האחורי הזה של הגינה?

ת': כשאני פגשתי את הדיירים שחיו שם לפני, הם הכירו את עניין הצעקות ומי שגר שם מאחורה אז אני מאמין שזה היה לפני. כל הזמן.

ש': למיטב ידיעתך מדובר על עוד שנה אחורה או 50 שנה אחורה?

ת': לא יודע.

ש': אמרת תמיד.

ת': תמיד הכוונה מיום שזה נבנה, משנות ה-90' או כנראה מאז ומתמיד" (עמ' 9 ש' 20 – 27 לפרוטוקול דיון הוכחות מיום 7.7.20, ההדגשות אינן במקור)

גם הוועדה המקומית אישרה במכתבה מיום 02.05.16, כי מדובר במחסן שהורחב לפני שנים רבות:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת- שלוחת עכו

מס' תיק: 8/148/2017 + 8/607\2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

**"קיימת יחידת דיור בשטח של כ-23 מ"ר וכל זאת ללא היתר בניה
כחוק, (ראוי לציין כי התוספת נבנתה לפני מספר רב של שנים וזאת
בהסתמך על תצ"א הנמצאים במשרדינו)..."**

ובנוסף כי עבירות השימוש שנעשות על ידי הנתבעת : **"קיימות מספר רב של שנים"**
(ההדגשות במקור).

47. כאמור, אין חולק כי חלק מהמחסן נבנה כדין באותה חצר, כך שהתביעה לסילוק יד מתייחסת רק לחלק מהמחסן החורג מ-9 מ"ר, ולשינוי השימוש בו ממחסן למגורים.

48. התובעים רכשו את דירתם רק בשנת 2013 או בסמוך לכך, כאשר הם מודעים היטב למצב הקיים בדבר חלוקת החצר בין בעלי הדירות לרבות המחסן שהורחב והשימוש שנעשה בו לאורך שנים, ולמרות זאת לא ניסו לברר מול בעלי הזכויות הקודמים האם אכן התגבשה הסכמה לחלוקת החצר, גם אם הסכמה שכזו השתכללה מכוחו של נוהג בן עשרות שנים.

49. התובעים לא הפריכו את טענת הנתבעת לפיה, אין מדובר ברישיון חינוך, שכן גם שאר בעלי הדירות עושים שימוש ייחודי בחלק מהחצר המשותפת, באופן שהנתבעת עושה שימוש ייחודי רק בחלק מהחצר האחורית של הבית :

א. ראשית, אין חולק כי גם לכל אחת מדירות התובעים נבנה מחסן ברכוש המשותף. גם אם מחסנים אלה קטנים יותר, יש בהם כדי ללמד על שימוש שנעשה ברכוש המשותף. המצהיר מטעם התובעים האדריכל יניב מנדל צירף לתצהירו מיום 28.12.17 תשריט בו סימן את שני מחסנים של התובעים.

אמנם המחסנים של התובעים נהרסו על ידם בשלב מאוחר יותר, במסגרת ההליך הנוכחי, אך גם זאת רק לאחר הגשת התביעה הנוכחית. העובדה כי המחסן נבנה על ידי הבעלים הקודם של דירת התובעים אינה רלבנטית, שכן די בבניית המחסן גם כן בחלק מהחצר כדי לתמוך בטענות הנתבעת בדבר חלוקה מסוימת של החצר שלפיה כל צד הקים מחסן בשטח שבו הוא עושה שימוש ייחודי.

ב. בנוסף, גם התובע מס' 3 בעצמו קיבל היתר בניה להרחיב גם כן את דירתו אך לא מימש את ההיתר. הנתבעת לא התנגדה להרחבה זו, והשימוש שנעשה על ידי הנתבעת בחצר האחורית לא מנע הרחבה זו.

ג. כבר בתצהיר הראשון שהגישה הנתבעת בתיק טענה הנתבעת, לקיומה של חלוקה מוסכמת של החצר המשותפת הנוהגת בין בעלי הדירות משך עשרות שנים, ולכך שבהתאם לחלוקה זו לא התנגדה ששאר בעלי הדירות ירחיבו את דירותיהם (ר' סעיפים 18 ו-19 לתצהיר מיום 20.1.2017 במסגרת בקשה לביטול פסק הדין). התובעים לא הפריכו חלוקה זו, וכאמור אישרו כי הנתבעת עושה שימוש ייחודי בחלק מהחצר משך תקופה ארוכה.

ד. באשר לטענת התובעים, כי הנתבעת ניצלה את העובדה שהייתה בעלת הדירה הראשונה בבניין והשתלטה על החצר האחורית, לפני שהגיעו שאר בעלי הדירות, הרי שטענה זו לא הוכחה. בכל מקרה עולה מחומר הראיות כי לכל הפחות התגבש נוהג בן עשרות שנים במהלכו הסכימו בעלי הדירות בהתנהגות לחלוקת החצר, כאשר אף בעל דירה לא ביקש להפסיק או לשנות חלוקה זו, אלא במסגרת התביעה הנוכחית משנת 2016.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת- שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/148/2017 + 8/607/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

50. בשולי הדברים ניתן עוד לציין כי יתכן שאחת מבעלי הדירות הגב' קטן (הבעלים הקודמים של דירת חברת לידר) אף מכרה לכאורה חלק מזכויות הבניה לנתבעת (26 מטר מזכויות הבניה בקרקע - ר' מסמך ת/4 מיום 1.8.11). לא הוכח כי הנתבעת ניצלה מעבר לזכויות הבניה היחסיות המוקנות לדירתה יחד עם הזכויות שרכשה. אמנם טענה זו של הנתבעת הועלתה לראשונה בדיון ההוכחות ולא הוזכרה בתצהיר הנתבעת, אלא שנציג התובעת מס' 2 אישר כי היה מודע לטענה זו, אך כאמור גם בלעדית, ומבלי לקבוע כי הנתבעת אכן רכשה זכויות אלה מהגב' קטן, היה מקום להכיר בקיומה של רשות בלתי הדירה, מהטעמים שפורטו לעיל.

51. לכל אלה יש להוסיף כי ביטולו של רישיון במקרקעין כפוף לשיקולי צדק, ובהם כאמור התקופה הארוכה בה נעשה השימוש במקרקעין, גילה של הנתבעת, העובדה שעסקין בשימוש שנעשה למגורים שהיה גלוי וידוע היטב לבעלי הדירות לאורך השנים, וכי הנתבעת עשתה שימוש זה לטובת נכדיה אותם גידלה לבדה, זאת לאחר ששני הוריהם נפטרו. לכך יש להוסיף כי התובעים לא הוכיחו כי חל שינוי נסיבות ממשי המצדיק כיום לבטל את הרישיון, וזאת כל עוד תאריך הנתבעת חיים.

52. במסגרת שיקולי הצדק יש גם לקחת בחשבון את הנזק הראייתי שנגרם לנתבעת - הגשת התביעה בחלוף תקופה כה ארוכה, לאחר שבעלה של הנתבעת כבר נפטר, גם גרם לנתבעת נזק ראייתי משמעותי, שיש בו כדי לפגוע בראיות ובעדויות שהיה בידי הנתבעת להביא כדי להוכיח כי אותה חלוקה, הייתה מוסכמת בין בעלי הדירות באותו זמן, וכי התפתח אותו נוהג מוסכם.

הנתבעת אישרה, כי מי שטיפל בהרחבת המחסן ובהכשרתו למגורים היה בעלה המנוח. התובעים עצמם אישרו כי בעלי הדירות דאז נפטרו ולכן לא ניתן היה לברר מולם האם אכן הושגה אותה הסכמה לחלוקת החצר. אמנם אותו נזק ראייתי אין בו כדי להצמיח זכות קניינית, אך יש בו, בצירוף שאר הנסיבות, ללמד על קיומה של רשות בלתי הדירה העומדת לנתבעת.

על דוקטרינת הנזק הראייתי ר' גם (ע"א 2919/07 **מדינת ישראל נ' גיא-ליפל**, עמ' 65 (פורסם בנבו) (19.9.10); וראה גם ע"א 7589/13 **Establishment Adoka נ' מכון ויצמן למדע**, עמ' 27-28 (פורסם בנבו) (8.6.15)).

לאור כל אלה יש להכיר בנתבעת כבעלת רישיון במקרקעין ובמחסן שהורחב, וזאת כל עוד תאריך הנתבעת חיים, זכות זו תעמוד לנתבעת בלבד.

קידום פרויקט תמ"א 38

53. התובעים רכשו את דירותיהם רק בשנים האחרונות ואישרו, כי הגשת התביעה נועדה לאפשר קידום פרויקט של תמ"א 38. אין לקבל טענה זו. ראשית, לא הוכח כי לא ניתן יהיה לקדם פרויקט של תמ"א אלא אם יהרס המחסן. שנית, כל עוד לא קודם באופן ממשי הפרויקט, ואף לא הוצגה הבקשה שבכוונת התובעים להגיש לוועדה המקומית, לא חל שינוי נסיבות ממשי המצדיק לבטל את הרישיון שניתן, לאור מכלול השיקולים שפורטו לעיל.

כך כבר נפסק בהקשר להליכי תמ"א כי במסגרת הליך שכזה שבו אחד המחסנים בבית משמש למגורים, וללא היתר, הרי שהתמורות להן זכאי בעל המחסן, אינן שוות ערך לתמורות שיקבלו בעלי הדירות (ר' למשל תיק 340/18 (י-ם) **הייפרט רבקה נ' רמוראנו לנק זהבה** (פורסם בנבו), וכן פסק דינה של כב' המפקחת י' ליבוביץ' בתיק (חי') 17/19 **עוזי מרדכי מנור נ' דן ירון** (פורסם בנבו)).

לשם השלמת התמונה ר' גם פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב - עש"א (ת"א) 48996-10-18 **כלב נ' בן אורי** (פורסם בנבו) - שם נפסק כי במסגרת עבודות חיזוק מוסמך מפקח גם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת- שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/148/2017 + 8/607\2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להורות על הריסת מחסן ובנייתו במיקום אחר, הגם ששם דובר על בניית מחסן גדול יותר במקום המחסן המקורי.

על כך הרצון הכללי לקדם פרויקט שכזה, אין בו לבדו, כדי להביא לביטול הרישיון בנסיבות המיוחדות של המקרה.

סעד נוסף בכתב התביעה

54. בתביעה 8/148/17 גם התבקש סעד למנות שמאי שיקבע מהי עלות הרכיבים המשותפים שעל התובעים לשלם, כדי להרחיב את דירתם מעל תוספת הבניה של הנתבעת. בשלב מאוחר יותר הודיעו התובעים כי הם מוותרים על סעד זה ובהתאם הוריתי בהחלטתי מיום 29.6.17 על מחיקתו.

התוצאה:

יש לדחות את התביעה. התובעים לא הוכיחו כי חלו אותן נסיבות המצדיקות את ביטול הרישיון שניתן לנתבעת.

הנתבעת זכאית להמשיך להחזיק במחסן ובחלק מהחצר כבת-רשות עד אריכות ימיה.

אין בדחיית התביעה כדי לשלול קידום פרויקט תמ"א 38. ככל שבמסגרת החלטה של הוועדה המקומית יקבע שיש להעתיק או להרוס את המחסן כתנאי לביצוע הפרויקט, לרבות סילוק יד מהחצר המשותפת וכי לא קיימת חלופה ממשית אחרת לביצוע הפרויקט, אפשר שתעמוד לתובעים עילת תביעה חדשה, כאשר לכל היותר זכויות הנתבעת באותו מחסן יגולמו בתמורה שתנתן לה, מבלי לקבוע כל עמדה לגופו של עניין.

יובהר כי אין בפסק הדין, כדי לפטור את הנתבעת מקבלת היתר בניה כנדרש על פי דין, לרבות עבור הרחבת המחסן ושינוי השימוש בו למגורים.

בנסיבות אלה, משלא הוכח כי התקבל היתר כדון, תוך שנדחו גם הטענות הקנייניות של הנתבעת, מצאתי שכל צד יישא בהוצאותיו, בתקווה שהדבר גם יסייע לצדדים להגיע להסכמות בעתיד.

ניתן בלשכתי היום, א' חשון תשפ"א, 19 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים. המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לצדדים, כמקובל.

**יובל וסרקרוג
מפקח רישום מקרקעין**